

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7291/2538

บริษัท นิกโก เมทัล อินดัสตรี โก, แอลที
ดี

นาย ชีวสุย แซ่ซื่อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 88, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27

เมื่อโจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ร. เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยให้มีอำนาจยื่นฟ้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร. จึงยอมมีอำนาจตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 วรรคสอง เมื่อโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุนยานอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานและมีร. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาเบิกความประกอบพยานเอกสารนั้นแม้ไม่มีพยานที่รู้เห็นการทำเอกสารดังกล่าวมาเบิกความแต่เอกสารดังกล่าวก็เข้าสู่สำนวนโดยชอบพยานเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและมีการผลิตสินค้าตามเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN กับรูปรอยประดิษฐ์ตามฟ้องออกจำหน่าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีตัวอักษรโรมันทั้งหมด 2 คำ โดยคำหลังคือ HORN มีตัวอักษรเหมือนกันทั้งสี่ตัวส่วนคำหน้าคงแตกต่างกันแต่เพียงคำว่า NIKKO ของโจทก์มีตัวอักษร K อยู่ 2 ตัวส่วนคำว่า NIKO ของจำเลยมีตัวอักษร K เพียง 1 ตัวอักษรโรมันดังกล่าวของโจทก์และของจำเลยก็อ่านออกเสียงคล้ายคลึงกันโดยของโจทก์อ่านออกเสียงว่า นิกโกฮอน ส่วนของจำเลยอ่านออกเสียงว่า นิโก้ฮอน รูปรอยประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลย

นั่นต่างเป็นสีขาวอยู่กลางพื้นสีดำโดยมีอักษรโรมันว่าNIKONIKOตามลำดับกำกับ
อยู่ด้านล่างของรูปรอยประดิษฐ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นเป็นรอยหยักขนาดใกล้เคียงกัน
คงต่างกันแต่เฉพาะทิศทางของลายเส้นเท่านั้นเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำ
ว่าNIKKOHORNและรูปNประดิษฐ์ของโจทก์สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยอีก
เครื่องหมายหนึ่งแม้จะมีตัวอักษรโรมันคำว่าMighty-mateVFD-150อยู่ด้วยก็ตามแต่
จุดเด่นของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็อยู่ที่คำว่าNIKOและรูปรอยประดิษฐ์ซึ่งคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังนี้เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำ
ว่าNIKKOHORNและรูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าวมาก่อนจำเลยแม้จำเลยได้นำ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนโจทก์ก็ยังคงมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าNIKKOHORNและรูปรอยประดิษฐ์นั้น
และในเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย แม้รูป
รอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยกับตัวอักษรโรมันบนกล่อง
บรรจุสินค้าแตรของจำเลยและตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรของโจทก์แตก
ต่างกันอยู่บ้างโดยตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลยมีคำ
ว่าNIKOMightymateVFD-150ส่วนตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรของ
โจทก์เป็นตัวอักษรโรมันคำว่าNIKOPower-mateSFD-100แต่ความแตกต่างดังกล่าว
ก็มีเพียงเล็กน้อยซึ่งสำหรับผู้ที่อ่านอักษรโรมันไม่ได้หากได้เห็นเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์และของจำเลยในขณะเดียวกันก็ยากที่จะกล่าวได้ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง
และแม้ผู้ที่อ่านอักษรโรมันได้หากไม่พิจารณาให้รอบคอบหรือได้เป็น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเวลากันก็น่าจะไม่สามารถสังเกตเห็น
ข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวการที่เครื่องหมายการค้าที่กล่องบรรจุ
สินค้าแตรของจำเลยมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่กล่องบรรจุสินค้าแตร
ของโจทก์โดยสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์เช่นนี้นับได้
ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือนสินค้าของโจทก์และ

เป็นการที่จำเลยได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าคำว่าNIKOHORNและรูปรอยประดิษฐ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเป็นการละเมิดต่อโจทก์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของจำเลยเป็นการลวงสาราณชนให้สับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าโดยเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่าNIKOHORNและรูปรอยประดิษฐ์เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์ร่วมในการผลิตและจำหน่ายทำให้สาธารณชนเสื่อมความนิยมในเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์มีผลทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าของโจทก์โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเดือนละ50,000บาทดังนี้

โจทก์หาได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ทำการลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์แต่อย่างใดไม่คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวให้ก็เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจึงไม่อาจวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวให้ได้ เมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในการลวงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับจดทะเบียนนั้นตามมาตรา29วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์อ้างว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิและเมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยได้เอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในฐานะลวงขายตามมาตรา29วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้และไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งนี้เพราะสิทธินั้นเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของบุคคลผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ตามคำขอเลขที่ 175865 ดีกว่าจำเลย ขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 151849 ทะเบียนเลขที่ 103443 และคำขอทะเบียนเลขที่ 162546 ทะเบียนเลขที่ 112093 ของจำเลย โดยให้จำเลยจัดการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า NIKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท ให้แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 151849 ทะเบียนเลขที่ 103443 และคำขอเลขที่ 162456 ทะเบียนเลขที่ 112093 กับสินค้าของจำเลยพร้อมทั้งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าขอเลขที่ 151849 ทะเบียนเลขที่ 103443 และคำขอเลขที่ 162546 ทะเบียนเลขที่ 112546 ออกไปจากทะเบียน

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายโรจนวิทย์เปเรร่า และนายธเนศเปเรร่า มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีแทนโจทก์ โจทก์เพียงมอบอำนาจให้ยื่นฟ้องคดีแทนโจทก์หรือแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงเท่านั้น การที่นายธเนศผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงชื่อแต่งตั้งให้นายฉัตรบดี จารุสกุล เป็นทนายความเพื่อยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ เป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจที่ได้รับมอบมาจากโจทก์ การที่นายฉัตรบดีลงชื่อในคำฟ้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย โจทก์มิได้เป็นผู้ผลิตและไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKO Mighty mate VFD-150 และเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKO HORN โดยจดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายเป็น

ทะเบียนเลขที่ 103443 และ 112093 จำเลยได้คัดค้านเครื่องหมายการค้าดังกล่าวขึ้น
เอง จำเลยไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่ได้
กระทำการใด ๆ อันเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าและ
เข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ จำเลยมิได้ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจำเลย ทั้งโจทก์มิได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามฟ้องในประเทศไทยโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN
และรูปรอยประดิษฐ์ตามคำขอเลขที่ 175865 ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 151849ทะเบียนที่ 103443 และตามคำขอเลขที่
162546 ทะเบียนเลขที่ 112093ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากจำเลยไม่
ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าว และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือน
ละ10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้า
รูปรอยประดิษฐ์และขอถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.9 ไม่ได้ระบุให้นายธเนศ เปเรร่าแต่งตั้งทนายความได้ คงระบุแต่ว่าให้ยื่นฟ้องคดีแทนโจทก์เท่านั้นนายธเนศ เปเรร่า แต่งตั้งนายฉัตรบดี จารุสกุล เป็นทนายโจทก์ไม่ได้ เพราะหนังสือมอบอำนาจมิได้ระบุข้อความเช่นนั้น นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 วรรคสอง บัญญัติว่า"ถ้าคู่ความ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดีผู้รับมอบอำนาจเช่นนั้นจะว่าความอย่างไร ทนายความไม่ได้แต่ยอมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาได้" ดังนั้นเมื่อโจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.9 มอบอำนาจให้นายธเนศ เปเรร่า เป็นผู้มอบอำนาจโดยให้มีอำนาจยื่นฟ้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายธเนศ เปเรร่าจึงย่อมมีอำนาจตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีนี้ได้ตามมาตรา 60 วรรคสองดังกล่าว

ที่จำเลยฎีกาว่า เอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.36 โจทก์มิได้นำพยานที่รู้เห็นในการมีอยู่หรือการทำขึ้นซึ่งพยานเอกสารดังกล่าวมาสืบ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีการผลิตสินค้าตามเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN กับรูปรอยประดิษฐ์ตามฟองออกจำหน่ายนั้น เมื่อโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน และมีนายธเนศ เปเรร่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาเบิกความประกอบพยานเอกสารนั้น แม้ไม่มีพยานที่รู้เห็นการทำเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.36 มาเบิกความ แต่เอกสารดังกล่าวก็เข้าสำนวนโดยชอบ ทั้งจำเลยมิได้มีพยานหลักฐานมานำสืบโต้แย้งให้เป็นเป็นอย่างอื่น พยานเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและมีการผลิตสินค้าตามเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN กับรูปรอยประดิษฐ์ตามฟองออกจำหน่าย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตามฟ้องของโจทก์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย และลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.4 เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า NIKO Mighty mate VFD-150 กับรูปรอยประดิษฐ์สีขาวบนพื้นสีดำ โดยรูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นรูปสายฟ้าแลบมีตัวอักษรโรมันคำว่า NIKO อยู่ใต้รูปสายฟ้าแลบนั้น ทั้งนี้โดยตัวอักษรและรูปรอยประดิษฐ์ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปหยดน้ำและเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.5 เป็นอักษรโรมันคำว่า NIKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์สีขาวบนพื้นสีดำ โดยรูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นรูปสายฟ้าแลบมีตัวอักษรโรมันคำว่า NIKO อยู่ใต้รูปรอยประดิษฐ์นั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.2 กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.5 แล้ว ก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดังกล่าวมีตัวอักษรโรมันทั้งหมด 2 คำ โดยคำหลังคือ HORN มีตัวอักษรโรมันเหมือนกันทั้งสี่ตัว ส่วนคำหน้าคงแตกต่างกันเพียงคำว่า NIKKO ของโจทก์มีตัวอักษร K อยู่ 2 ตัว ส่วนคำว่า NIKO ของจำเลยมีตัวอักษรk เพียงตัวเดียว ตัวอักษรโรมันดังกล่าวของโจทก์และของจำเลยก็อ่านออกเสียงคล้ายคลึงกัน โดยของโจทก์อ่านออกเสียงว่านิโก ฮอน ส่วนของจำเลยออกเสียงว่า นิโก้ ฮอน รูปรอยประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยนั้นต่างเป็นสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปรอยประดิษฐ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นเป็นรอยหยักขนาดใกล้เคียงกัน คงต่างกันแต่เฉพาะทิศทางของลายเส้นเท่านั้นเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า NIKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์สายฟ้าแลบของจำเลยตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.5 จึงแทบจะไม่มีข้อแตกต่างจาก

เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า NIKKO HORN และรูป N ประดิษฐ์ของโจทก์ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 2 สำหรับ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามสำเนาคำขอเครื่องหมายการค้าเอกสาร จ.4 นั้น แม้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีตัวอักษรโรมันคำว่า Mighty mate VFD-150 อยู่ด้วย
ก็ตาม แต่จุดเด่นของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็อยู่ที่คำว่า NIKO และรูปรอย
ประดิษฐ์ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามสำเนาคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษร
โรมันคำว่า NIKKO HORN และรูป N ประดิษฐ์ตามฟ้องในประเทศญี่ปุ่นในปี 2510
และปี 2511 และต่อมาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซียและไต้หวันอีกด้วย โดยโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าอักษร
โรมัน NIKKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าวกับสินค้าแตรของรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ของโจทก์ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยนครกมลการได้สั่งสินค้าแตรของโจทก์
มาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2520 จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า
อักษรโรมันคำว่า NIKKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ตามฟ้องมาก่อนจำเลย แม้
จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
สำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ก่อน โจทก์ก็
ยังคงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า NIKKO HORN และรูปรอย
ประดิษฐ์ตามฟ้องและในเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดี
กว่าจำเลย เมื่อนำกล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลยมาเปรียบเทียบกับกล่องบรรจุ
สินค้าแตรของโจทก์แล้ว ก็ปรากฏว่ากล่องบรรจุสินค้าแตรวัตถุพยานหมายเลข จ.ง.2
ของจำเลยมีขนาดเท่ากับกล่องบรรจุสินค้าแตรวัตถุพยานหมายเลข จ.ว.1 ของโจทก์ รูป
ร่างลักษณะของกล่องตลอดจนสีของกล่องและตัวอักษรทุกด้านก็เป็นสีเดียวกันคือ
พื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำและสีขาวมีรูปรอยประดิษฐ์สีขาวพื้นสีเหลี่ยมสีดำและมีเส้นสี
ขาวขวางกลางด้านบนและด้านล่างในตำแหน่งเดียวกัน ขนาดของภาพและตัวอักษร

ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เท่ากัน และแม้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง อาทิเช่น กล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.2ของจำเลยมีตัวอักษรโรมันคำว่า NIKO HORN และ NIKO ELECTRIC HORNINDRSTRY ส่วนกล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.1 ของโจทก์มีตัวอักษรโรมันคำว่า NIKKO HORN และ NIKKO METAL INDUSTRY CO., LTD.และรูปรอยประดิษฐ์บนกล่องสินค้าแตรของจำเลยและโจทก์แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวก็มีเพียงเล็กน้อย สำหรับกล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.5 ของจำเลยนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.3ของโจทก์แล้ว ก็ปรากฏว่ากล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลยและของโจทก์ดังกล่าวมีขนาดใกล้เคียงกัน มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันพื้นด้านหน้าเป็นสีฟ้าและสีแสดมีกรอบนอกเป็นสีขาว 3 ด้าน โดยกล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลยด้านหน้ามีตัวอักษรโรมันสีฟ้าคำว่าNIKO Mighty mate VFD-150 และรูปรอยประดิษฐ์สีขาวของจำเลยกับตัวอักษรโรมันสีขาวคำว่า NIKO บนพื้นสีเหลี่ยมสีแสดอยู่ในกรอบรูปหยดน้ำพื้นสีขาวล้อมรอบด้วยพื้นสีฟ้า ส่วนกล่องบรรจุสินค้าแตรของโจทก์มีตัวอักษรโรมันสีฟ้าคำว่า NIKKO power mate SFD-100และรูปรอยประดิษฐ์สีขาวของโจทก์กับตัวอักษรโรมันสีขาวคำว่าNIKKO บนพื้นสีเหลี่ยมสีแสดอยู่ในกรอบรูปหยดน้ำพื้นสีขาวล้อมรอบด้วยพื้นสีฟ้า ด้านล่างของกล่องบรรจุสินค้าทั้งสองเป็นพื้นสีขาวไม่มีตัวอักษรหรือลวดลายใด ด้านข้างทั้งสี่ด้านของกล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลยและโจทก์ดังกล่าวมีพื้น สี และลวดลายคล้ายกัน โดยมีตัวอักษรโรมันและรูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์พิมพ์ลงบนพื้นดังกล่าวด้วยสีเดียวกันขนาดของตัวอักษรและรูปรอยประดิษฐ์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้ แม้รูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยกับตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.5 ของจำเลยและตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรวัดอุณหภูมิ จ.ว.3 ของโจทก์แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแตรของจำเลย

มีคำว่า NIKOmighty mate VFD-150 ส่วนตัวอักษรโรมันบนกล่องบรรจุสินค้าแต่
ของโจทก์เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า NIKO power mate SFD-100แต่ความแตกต่าง
ดังกล่าวก็มีเพียงเล็กน้อยซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อ่านอักษรโรมันไม่ได้ หากได้เห็น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยในขณะเดียวกัน ก็ยากที่จะกล่าวได้ว่ามี
อะไรแตกต่างกันบ้างและแม้ที่ผู้ที่ไม่อ่านอักษรโรมันได้ หากไม่พิจารณาให้รอบครอบ
หรือได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเวลากันก็น่าจะไม่สามารถ
สังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นเครื่องหมายการค้า
อักษรโรมันคำว่าNIKO Mighty mate VFD-150 กับรูปรอยประดิษฐ์ในกรอบรูปหยด
น้ำที่ปรากฏบนกล่องบรรจุสินค้าแต่วัตถุพยานหมาย จ.ว.5 อันเป็น
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย
จ.4 นั้นก็ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามที่ปรากฏอยู่
บนกล่องบรรจุสินค้าแต่วัตถุพยานหมาย จ.ว.4ของโจทก์ซึ่งเป็นอักษรโรมันคำว่า
NILLO Mighty mate VFD-125กับรูปรอยประดิษฐ์ในกรอบรูปหยดน้ำอีกด้วย การที่
เครื่องหมายการค้าที่กล่องบรรจุสินค้าแต่ของจำเลยมีลักษณะคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าที่กล่องบรรจุสินค้าแต่ของโจทก์ โดยสินค้าของจำเลยเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์เช่นนี้นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลง
ผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยลอกเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าตามฟ้องของโจทก์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยอย่างไรก็ดี โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าคำว่า
NIKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยอันเป็นการกระทำโดย
ไม่สุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของจำเลยเป็นการลวง
สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าโดยเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า NIKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์เป็นสินค้าของโจทก์

หรือโจทก์ร่วมในการผลิตและจำหน่าย ทำให้สาธารณชนเสื่อมความนิยมใน
เครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์ มีผลทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการ
จำหน่ายสินค้าของโจทก์ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท ดังนี้ โจทก์หา
ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ทำการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์แต่
อย่างใดไม่ คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็น
สินค้าของโจทก์หรือไม่ แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าว
ให้ ก็เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่
อาจวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวให้ได้

ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยนั้น เมื่อปรากฏ
ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN และรูป N ประดิษฐ์ของโจทก์ตามคำขอ
จดทะเบียนเลขที่ 175865 เอกสารหมาย จ.2 ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนนั้น ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2474 อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์อ้างว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิ และเมื่อ
โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยได้เอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็น
สินค้าของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในฐานะลงขายตามมาตรา 29
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ค่าเสียหายแก่
โจทก์เดือนละ 10,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้า
ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยข้อที่โจทก์แก้ฎีกาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขอให้ศาลฎีกา
พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่วัน
ฟ้องเต็มตามที่โจทก์ฟ้องต่อไป

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ของจำเลยและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งนี้เพราะสิทธินั้นเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของบุคคลผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เท่านั้น ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า NIKKO HORN และรูปรอยประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 175865 ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ 103443 และเลขที่ 112093 คำขออื่นให้ยก

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ